

1502403-28.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... patrulhamento em via já conhecida do tráfico de entorpecente. Na biqueira sempre tem pessoas no tráfico de entorpecentes. O acusado, ao avistar a viatura, avisou ao amigo adolescente que a viatura estava vindo e, nesse momento os dois tentaram se evadir. Na abordagem localizaram certa quantidade de cocaína, maconha, crack e R\$ 192,00. O réu gritou "moiô, moiô, a viatura". O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1502403-28.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502403-28.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2024739/2021 - 46º D.P. PERUS, 15908714 - 46º D.P. PERUS, 167/21/346 - 46º D.P. PERUS, 2024739 - 46º D.P. PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN JOHNNY OLIVEIRA DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ALLAN JOHNNY OLIVEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput c.c. o artigo 40, VI (corrupção de adolescente para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (em ocasião de calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), na manhã de 27 de janeiro de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Mogeiro nº 1661, Perus, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso com o adolescente Josias Ostan, foi surpreendido vendendo e trazendo consigo, em ocasião de calamidade pública, para o tráfico de drogas, 67 (sessenta e sete) microtubos plásticos contendo cocaína, 8 (oito) porções de maconha e 46

(quarenta e seis) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Josias Ostan, à época com dezessete anos de idade, com ele praticando as infrações penais mencionadas. Relata a inicial que, segundo apurado nos autos, Policiais Militares, em patrulhamento pelo local dos fatos, visualizaram o denunciado e o adolescente, que aparentavam estar em atividade de traficância. Ao notar a aproximação da viatura, o denunciado alertou o adolescente e ambos tentaram empreender fuga, mas não tiveram êxito.

Narra ainda a inicial que feita a abordagem, foi encontrada uma sacola plástica contendo as porções das drogas destinadas a venda e a quantia de R\$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) em notas de pequeno valor, produto da traficância. Por decisão datada de 28 de janeiro de 2021, foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 57/60).

A denúncia foi recebida (fls. 91/92).

O Réu foi citado (fl. 103) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado. Foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares arroladas em comum pelas Partes e, em seguida, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, seguiram-se os memoriais finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; c) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; d) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; e) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal colhe foros de parcial procedência.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a autoria.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade está confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/07), Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), Laudo de Constatação (fls. 26/29), Fotografia (fl. 29), Laudo Definitivo de Exame Químico Toxicológico (fls. 121/123), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

A testemunha policial militar José Rafael Garcia Rocha, em seu depoimento prestado

em juízo narrou, em suma, que durante o patrulhamento em via já conhecida do tráfico de entorpecente. Na biqueira sempre tem pessoas no tráfico de entorpecentes. O acusado, ao avistar a viatura, avisou ao amigo adolescente que a viatura estava vindo e, nesse momento os dois tentaram se evadir. Na abordagem localizaram certa quantidade de cocaína, maconha, crack e R\$ 192,00. O réu gritou "moiô, moiô, a viatura". O dinheiro estava com o Réu Allan. O adolescente assumiu que estava no tráfico com Allan. Tinha uma moça, não se recorda o nome dela. Aparentemente ela não estava no tráfico, porque ela não correu. A droga estava em sacola na mão do adolescente.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Ana Paula Rosa Ribeiro, extraíndo-se de seu depoimento, em síntese, que estava em patrulhamento, é um ponto conhecido de tráfico, quando visualizaram o indivíduo que, se não se engana, gritou alguma coisa para um adolescente e correram. Abordaram os dois. Encontraram certa quantia de entorpecente e valores em dinheiro. O entorpecente estava com o menor e o dinheiro estava com o que gritou "moiô". Tinha uma moça que não correu.

Ao ser interrogado em juízo o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas. Extrai-se de seu interrogatório, em síntese, que está com 21 anos de idade. Estudou até o primeiro ano do ensino médio. Está fazendo "bico" de pedreiro quando aparece. Mora com os pais e três irmãs. Estava conversando com a menina. Não gritou "moiô". Não conhecia os policiais, nunca tinha sido abordado por esses policiais antes. Não tinha dinheiro nenhum. Acha que o dinheiro era do menino que eles pegaram. Conhecia Josias apenas de vista do local onde mora. Não estavam juntos. Ocorre que, diante dos depoimentos das testemunhas policiais e demais elementos de prova, a versão apresentada pelo réu no sentido de que não estava na prática do tráfico juntamente com o adolescente restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse a sua versão.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais foram uníssomos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

A finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza, quantidade e variedade de droga apreendida; b) pela forma de acondicionamento da droga; c) pelas circunstâncias da prisão; d) apreensão da importância em dinheiro no valor de R\$ 192,00.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06.

Dispõe o aludido dispositivo que: "Art. 40 - As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo,

diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação". (grifos nossos).

Restou demonstrado que a apreensão dos entorpecentes envolvia o adolescente Josias Ostan, com 17 anos de idade, sendo aplicável a mencionada causa de aumento de pena.

Do afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal

No tocante à agravante de ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública, em que pese o Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020 ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime de tráfico de drogas, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O decreto de estado de calamidade pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus Covid19 não autoriza automaticamente o reconhecimento da referida agravante a todos os crimes praticados enquanto perdurar a calamidade. Necessária a existência de relação do tráfico com o estado de calamidade, valendo-se, por exemplo, o agente das facilidades que dela decorrer, que garanta a impunidade ou que o beneficie, de qualquer forma, o que não se revela nos autos." (Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021) (grifos nossos)

No mesmo sentido: Apelação Criminal 1509934-05.2020.8.26.0228 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Mazina Martins, de 14 de outubro de 2021, e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente que possa ser considerado desabonador, conforme se infere da Certidão as fls.

96/97. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 anos na data do fato, tendo à época, 19 anos de idade. Deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, aumento a pena de um sexto, culminando com a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ainda em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 194 dias-multa.

Consoante os ensinamentos de Ricardo Antonio Andreucci, Promotor de Justiça Criminal de São Paulo, em Legislação Penal Especial, Editora Saraiva, 3ª Edição, 2007, pág. 54: "Portanto, caberá ao Ministério Público, no processo, provar que o

agente se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. Sem essa prova, a causa de diminuição de pena não poderá deixar de ser aplicada, satisfeitos os demais requisitos legais". (grifos nossos).

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, contava com 19 anos à época dos fatos, sem antecedentes desabonadores, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena quantidade de droga (0,2 decigramas) de crack, legítima é a aplicação da causa especial de diminuição (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) pelo seu máximo, ou seja, dois terços.

Precedentes. 3. A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos Nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Também conforme elucidativo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecente. Réus flagrados promovendo o tráfico no local. Quantidade de 16 porções de cocaína, pesando 22,52 gramas, e 4 porções de crack, com peso de 1,58 gramas. Campana policial. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares. Intenção negocial comprovada. Condenação mantida. Penas dosadas nos mínimos legais. Redutor aplicado à razão de dois terços. Regime fechado afastado. Reforma para o regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento." (Apelação nº 0005221-82.2012.8.26.0441. Relator Guilherme de Souza Nucci. São Paulo, 23 de fevereiro de 2016.). (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado ALLAN JOHNNY OLIVEIRA DOS SANTOS,

qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 194 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA